

1502136-32.2020.8.26.0118

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIGI MONTEIRO SESTARI

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória por tráfico privilegiado. Recursos da defesa e da acusação. - Absolvição inadmissível.

Comprovadas autoria e materialidade. Conduta de ter em depósito e guardar, para o tráfico, um tijolo de maconha (peso líquido de 679,4g). Afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia-SP - cep 11990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502136-32.2020.8.26.0118 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502136-32.2020.8.26.0118

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2103856/2020 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 11144037 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA,

222/20/436 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2103856 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA,

222/20/436 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KARINE DE JESUS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIGI MONTEIRO SESTARI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu presentante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia ROBERTO APARECIDO FERREIRA e KARINE DE JESUS PEREIRA, como incurso na prática do delito tipificado no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que:

"Consta dos incluídos autos de inquérito policial que, no dia 28 de abril de 2020, por volta das 06h00, na Rua Militão Martins Simões, nº 180, em Acaraú, nesta cidade e comarca de Cananeia, ROBERTO APARECIDO FERREIRA, vulgo "Jow", "Biguá" e "Diego", qualificado indiretamente à fl. 69, e KARINE DE JESUS PEREIRA, qualificada à fl. 21, guardavam e tinham em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, drogas

consistentes em 22 porções de cocaína, pesando aproximadamente 444,0g, e outras 66 porções de cocaína na forma de "crack", pesando aproximadamente 228,0g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o auto de exibição e apreensão de fl. 13/15 e o auto de constatação preliminar fl. 12. No dia 28 de abril de 2020, ROBERTO APARECIDO FERREIRA, vulgo "Jow" ou "Biguá", e sua companheira, KARINE DE JESUS PEREIRA, guardavam e tinham em depósito, no interior da residência que dividiam, localizada na Rua Militão Martins Simões, nº 180, em Acaraú, nesta cidade e comarca de Cananeia, as drogas acima descritas, as quais ROBERTO também preparava, distribuía e vendia. Ocorreu que, por volta das 06h00, a Polícia Civil se dirigiu ao local para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de ROBERTO. Lá chegando, KARINE franqueou a entrada. No interior do imóvel, foram encontrados: 66 porções de "crack", 61 embaladas individualmente, e 5 a granel de "crack"; 22 porções de cocaína, 14 embaladas individualmente, e outras 8 a granel; 669 cápsulas eppendorfs vazias; 500 embalagens plásticas; 340 comprimidos brancos; 2 balanças de precisão; 3 lâminas de barbear; um rolo de filme PVC; 2 folhas contendo anotações do tráfico de entorpecentes; um contrato de aluguel em nome de ROBERTO APARECIDO FERREIRA; um aparelho de telefonia celular; a quantia de R\$ 665,00, em dinheiro; e 4 comprovantes de depósitos bancários. ROBERTO não foi encontrado, mas KARINE confirmou que ele é "quem traz [a droga] para Cananeia, prepara em casa, põe nos saquinhos de 'chup-chup', divide, embala e depois entrega para outros venderem". As circunstâncias da prisão em flagrante de KARINE, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, os petrechos, a quantia em dinheiro, em espécie, e as anotações sobre o tráfico encontradas, além das informações da Polícia Civil que embasaram a concessão do mandado de busca e apreensão e da confirmação de KARINE bem evidenciavam que ela e ROBERTO realizavam o tráfico de drogas no local."

A denúncia foi recebida em 29 de maio de 2020 (fls. 97/100).

A acusada KARINE apresentou defesa prévia (fls. 200/203) e, com relação ao corréu ROBERTO, tendo em vista sua não localização, desmembrou-se o feito.

Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 205/206).

Em audiência de fls. 268/274, foram ouvidas as testemunhas de acusação Armando Márcio Costa e Nelson Galdino de Oliveira e as testemunhas de defesa Priscila Leme da Silva, Kawani de Jesus Pereira e Emily de Jesus Pereira., bem como interrogado a acusada KARINE.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais escritos.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada com a fixação de regime fechado (fls. 280/285).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado e os benefícios penais cabíveis (fls. 289/292).

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, observado o disposto na Lei nº 8.072/1990.

A materialidade delitiva resultou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de constatação preliminar (fl. 15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), fotografias de pesagem das drogas (fls. 19/22 e 31), laudo de objetos apreendidos relacionados ao tráfico (fls. 134/149 e 150/152), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 126/133 e 155/158), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. A testemunha ARMANDO MÁRCIO COSTA, policial civil, disse em juízo que no dia dos

fatos foi cumprir um mandando de busca e apreensão decorrente de uma investigação em que o alvo era o marido da ré KARINE, o Sr. ROBERTO, por suposto crime de tráfico de drogas. Ao adentrar na residência foi recebido por KARINE, já que ROBERTO não se encontrava. A ré franqueou a entrada dos policiais, foi perguntado a ela sobre a existência de drogas e armas em sua residência, momento em que a ré KARINE apontou as drogas, cocaína e crack, que estavam escondidas em uma bolsa, ao lado de um fogão, de fácil acesso. Quando indagada sobre a procedência das drogas, informou que estava guardando para seu marido, mas era ele quem preparava os entorpecentes e os vendia na cidade. Na residência ainda se encontrava uma criança de aproximadamente um ano e uma prima de KARINE, adolescente de aproximadamente 15 anos.

Da mesma forma, a testemunha NELSON GALDINO DE OLIVEIRA, policial civil, disse que no dia dos fatos diligenciou para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do alvo ROBERTO, marido da ré KARINE, pelo suposto envolvimento dele com o tráfico de drogas na localidade. Ao se aproximar da residência, KARINE franqueou a entrada dos policiais, momento em que foi questionada sobre seu marido ROBERTO e se havia algo de ilícito na residência. A ré informou que ele não se encontrava, mas prontamente indicou os locais onde estavam guardadas as drogas e os objetos utilizados para acondicionar estas.

A testemunha de defesa PRISCILA LEME DA SILVA nada soube dizer sobre os fatos, apenas informou que a família de KARINE é de Iguape/SP e ela também reside em Iguape.

KAWANI DE JESUS PEREIRA, irmã da acusada, ouvida na qualidade de informante, disse que KARINE trabalhava de manicure para se manter, já que não estava mais em um relacionamento amoroso com ROBERTO. Afirmou que estava residindo na casa de KARINE há um mês e meio e não viu as drogas que foram apreendidas pela polícia.

EMILY DE JESUS PEREIRA, irmã da acusada, ouvida na qualidade de informante, disse que estava na residência quando os policiais civis surgiram para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Informou que KARINE trabalha como manicure e que nunca tinha visto ela ou qualquer pessoa adentrando na residência para comprar drogas.

A ré KARINE DE JESUS PEREIRA, em sede policial, disse que as drogas encontradas eram de ROBERTO e que ele realizava o tráfico de drogas em Cananéia. Informou que ele foi à São Paulo para levar a quantia de três mil reais para uma pessoa.

Ouvida em juízo, alterou sua versão, confessando a prática delitiva. Disse que estava já separada de ROBERTO e por não poder mais trabalhar, por estar em fase de gestação, aceitou guardar as drogas para "uma pessoa" para poder ter dinheiro para sua subsistência.

A "confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial" (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

Aliás, leciona ADALBERTO JOSÉ QUEIROZ TELLES DE CAMARGO ARANHA que "a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa" ("Da Prova no Processo Penal", ed. Saraiva, 1999, p. 114).

No caso dos autos, a confissão da ré não é elemento isolado, pelo contrário, vem fortalecida pelo restante do conjunto probatório, notadamente o testemunho dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante quando encontraram, no interior da residência da ré KARINE, as drogas apreendidas em uma bolsa ao lado de um fogão, local que a própria ré KARINE apontou para os milicianos como o ambiente onde guardava os entorpecentes a mando de seu ex-companheiro.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas

palavras.

Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

A jurisprudência segue igualmente:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ AC Rel. Synésio de Aquino RDTJR 7/287).

“Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum” (in

“Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

A ré também guardava e tinha em depósito diversas quantidades de drogas (cocaína e crack), notadamente 66 porções de “crack”, pesando aproximadamente 444,0g, 61 embaladas individualmente, e 5 a granel de “crack”, 22 porções de cocaína, pesando aproximadamente 228,0g, 14 embaladas individualmente, e outras 8 a granel, juntamente com petrechos para fabricação dos entorpecentes, 669 cápsulas eppendorfs vazias, 500 embalagens plásticas; 340 comprimidos brancos, 2 balanças de precisão, 3 lâminas de barbear, um rolo de filme PVC e 2 folhas contendo anotações do tráfico de entorpecentes. bem como em sua posse foram apreendidos R\$ 665,00 em dinheiro, o que denota a mercancia dos entorpecentes.

É a jurisprudência pacífica deste E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Validade do depoimento dos policiais – Circunstâncias da apreensão, aliadas à diversidade e natureza das drogas, bem como à presença de dinheiro, que evidenciam a destinação à mercancia – Descabida a desclassificação perseguida – Condenação bem decretada – Penas acertadamente dosadas – Não caracteriza 'bis in idem' a valoração de uma condenação definitiva como circunstância desfavorável, na primeira fase, e, de outra, como agravante, na segunda etapa do itinerário trifásico – Caracterizada a recidiva, a fração de acréscimo se afigura como discricionariiedade do magistrado – Incremento em patamar superior ao de 1/6 que se apresentou adequado, notadamente em razão da multirreincidência – Precedente – Recidiva que obsta a aplicação do redutor disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 – Persistência da majorante elencada no art. 40, VI, da Lei de Drogas – Idades dos menores comprovadas por meio do boletim de ocorrência – Validade – Precedente – Regime prisional fechado único adequado à espécie – Detração penal – Descabimento – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Recurso

desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500049-98.2020.8.26.0540; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em conhecido ponto de mercancia espúria em poder de 53 porções de cocaína, pesando 38,7 gramas, 20 porções de maconha, com peso de 43,9 gramas, e 20 pedras de crack, pesando 4,3 gramas, além da quantia de R\$ 122,00. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares.

Confissão do acusado. Diversidade de drogas que confirmam a posse para fins mercantis. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à fração máxima. Imposição de regime aberto. Cabível substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Parcial

provimento ao apelo defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 0001132-63.2018.8.26.0616; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

No tocante à tipicidade, é assente na doutrina e na jurisprudência que para a caracterização do crime de tráfico de drogas não é necessário que haja provas da comercialização, ou que o réu venha, de fato, a vender entorpecentes, bastando que pratique quaisquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista tratar-se de tipo misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, que traz dezoito verbos distintos, sendo certo que, no presente caso, o acusado incorreu na prática do núcleo do tipo "guardar e ter em depósito" com o intuito de dispensar as drogas no mercado ilícito.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJSP:

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Quantidade da droga e forma de acondicionamento que evidenciam a prática da traficância. Reconhecimento do delito em sua modalidade tentada. Não cabimento. O tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo. Possuindo 18 ações distintas, o delito se consuma com a prática de um dos núcleos do tipo penal. A conduta "trazer consigo" é delito de mera conduta, que não admite a modalidade tentada. Aplicação do redutor do §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima. Quantidade de droga apreendida que não pode ser considerada expressiva tendo em vista o local de cometimento do delito - a cidade de São Paulo. Fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face da quantidade de pena aplicada e da primariedade do agente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001899-83.2014.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/12/2015; Data de Registro: 04/12/2015)

Desse modo, a conduta da ré se subsume perfeitamente ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Assim sendo, estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do fato que sobre ele recai.

Ainda, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que preenchidos todos os requisitos para tanto, pois a acusada é primária e não possui antecedentes (fls. 293), bem como não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Na espécie, foram apreendidas diversas quantidades de drogas (cocaína e crack), no entanto, quantidade esta que, apesar da diversidade, não impede a aplicação do redutor na terceira fase, posto não configurar o requisito de dedicação à atividade criminosa.

Ademais, a ré KARINE, ao que se demonstrou da prova oral colhida nos autos, notadamente de seu próprio interrogatório e do testemunho dos policiais civis, atuou como mera guardadora das drogas de propriedade de seu ex-companheiro ROBERTO, não podendo ser considerada, pelos elementos colhidos nos autos, como alguém dedicada à atividade criminosa.

Diferentemente é o caso de seu ex-companheiro que não foi encontrado nestes autos e o processo foi desmembrado.

Este sim, pela prova colhida nestes autos, era quem realizava o tráfico ativamente nesta cidade, tanto que consta como locatário do imóvel em que residiam, realizava anotações para fins de controle das vendas de drogas e manufaturava os entorpecentes na residência para posterior dispensação no mercado ilícito.

Em caso análogo, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória por tráfico privilegiado. Recursos da defesa e da acusação. - Absolvição inadmissível.

Comprovadas autoria e materialidade. Conduta de ter em depósito e guardar, para o tráfico, um tijolo de maconha (peso líquido de 679,4g). Afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Quantidade e natureza que não comprovam estivesse o réu dedicado à atividade criminosa ou que integre organização criminosa.

Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas incabível. Confissão espontânea condizente com as provas dos autos. Réu primário e de bons antecedentes. Penas e regime aberto compatíveis. Aplicação do art. 44 do Código Penal. Compatível. Precedentes. – Recurso ministerial desprovido; recurso da defesa parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão. (TJSP; Apelação Criminal 1501044-77.2020.8.26.0228; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada. (HC 195319 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 04-03-2021 PUBLIC 05-03-2021)

Por não haver qualquer circunstância que o impeça, a redução deverá se dar em seu grau máximo, qual seja, em dois terços (2/3).

Por fim, a acusada era imputável na data dos fatos, tinha consciência do caráter ilícito de sua conduta, e não há quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal e atento às circunstâncias preponderantes elencadas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social da conduta do agente, não há motivos para maior valoração da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, a acusada não possui condenação anterior, sendo, portanto, ré primária e sem antecedentes. No que diz respeito à conduta social, deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos. Dessa forma, por não haver nos autos qualquer informação acerca da convivência social do acusado, não há elementos para valoração da conduta social. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, foram apreendidas quantidades de drogas diversas (cocaína e crack) superiores apenas a meio quilograma, quantidade esta que, apesar da diversidade, não enseja majoração da pena-base, nem impede a aplicação do redutor na terceira fase, consoante jurisprudência deste E. TJSP em casos semelhantes (Apelação Criminal 1501044-77.2020.8.26.0228; Relator OSNI PEREIRA; 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021 e Apelação Criminal nº 0001132-63.2018.8.26.061, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgado em 05/02/2021). Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa a obtenção de lucro fácil, não se importando com o mal que o usuário e destinatário da droga possa sofrer. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com

resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Quanto à personalidade do agente, refere-se a um conjunto somatopsíquico (ou psicossomático), exigindo formação técnica. No caso, não há dados nos autos para aferição desta circunstância. Por fim, ante a natureza do delito, não há falar-se em comportamento da vítima. Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, vislumbro a presença da atenuante de confissão espontânea, mas diante da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, ante o teor da Súmula nº 231 do C. STJ, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há nenhuma causa de aumento de pena a ser aplicada, posto que o requerimento do Ministério Público para aplicação do art. 40, III, da Lei de Drogas é totalmente descabido, não havendo sequer narrativa do fato que ensejaria a causa de aumento, muito menos prova de que o tráfico teria sido praticado nas imediações de algum dos estabelecimentos elencados na referida lei. Por outro lado, a acusada é primária, possui bons antecedentes, e não há provas de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reduzindo a pena em dois terços (2/3), estabelecendo a pena definitiva em de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Considerando a ausência de informações precisas acerca da situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 49, § 1º, do Código Penal e 43 da Lei 11.343/2006).

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§2º e 3º do Código Penal).

Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluindo-se aí o tráfico de drogas, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e nas Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF.

Vide para tanto a ementa:

Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o

art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. (HC 111840, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1052700, com REPERCUSSÃO GERAL, julgado em 02/11/2017, considerando inconstitucional a fixação ex lege do regime inicial fechado com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Assim, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e primariedade do agente, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena, tudo na forma do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal, mediante o cumprimento das condições elencadas no art. 115 da Lei de Execuções Penais.

Destaco que deixo de aplicar a detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a matéria é afeta ao Juízo da Execução, posto que ausente requisito subjetivo nos autos para tanto.

A pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o delito não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Por isso, forte no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em:

a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, em entidade assistencial ou outro estabelecimento congênere, a ser indicado pelo Juízo da execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, § 3º, do Código Penal); e, b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 01 (um) salário-mínimo. A forma de pagamento da prestação pecuniária será estabelecida em audiência admonitória a ser oportunamente designada.

Trata-se das medidas restritivas que se mostram mais consentâneas às circunstâncias que norteiam o fato praticado e às condições pessoais do réu, haja vista que esta Comarca não dispõe de local adequado para cumprimento da pena de limitação de fim de semana, sendo certo que o cumprimento desta medida em prisão domiciliar não atende às finalidades da pena, por não haver qualquer fiscalização.

Ante a substituição acima operada, fica prejudicada a análise do cabimento da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para o fim de CONDENAR a acusada KARINE DE JESUS PEREIRA, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial ABERTO, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Considerando que a ré foi condenada ao cumprimento da pena em regime aberto e que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, entendo que não há razoabilidade em se manter as medidas cautelares outrora impostas (art. 387, § 1º, CPP). Assim, REVOGO A PRISÃO DOMICILIAR anteriormente fixada (fls. 48/52).

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Condene a sentenciada também ao pagamento das custas e despesas processuais.

No caso, considerando que compete à acusada a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006) e ausente tal comprovação, DECRETO O PERDIMENTO dos valores apreendidos R\$ 665,00, devendo ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;
Com relação à pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);
Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;
Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;
Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;
Ofícios de praxe;
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Cananeia, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA